

淫，其行为均已构成容留他人卖淫罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，系主犯；被告人于某起次要作用，系从犯。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯。被告人李某某、于某归案后均如实供述罪行。被告人于某自愿认罪认罚。

关于被告人李某某及其辩护人提出卖淫人员的嫖资分成不应当视为李某某非法获利的辩解和辩护意见。法院认为，在容留卖淫罪中，容留者提供场所，卖淫者进行卖淫活动，容留者对卖淫者没有管理控制特征，双方不构成共同犯罪关系，只是相互利用关系，卖淫者的提成分成不能视为容留者处分非法获利。故本案卖淫者从嫖资中的提成分成不应当计算为作为容留者的被告人李某某的非法获利，但其他经营成本包括场地费用、支付给同案被告人的好处等是李某某为实施犯罪支出的成本，不应当从嫖资中剔除。综上，经核算，认定本案中容留卖淫罪的非法获利为25600余元。相应的辩解和辩护意见，予以采纳。

据此，江苏省无锡市惠山区人民法院作出如下判决：

一、被告人李某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；

二、被告人于某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；

三、没收被告人于某退出的违法所得人民币800元，上缴国库；追缴被告人李某某的违法所得人民币24800元，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具被告人李某某手机2部，由公安机关予以没收；扣押在案的被告人于某的手机1部，由公安机关依法处理。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案争议的焦点在于被告人犯容留卖淫罪时非法获利数额的认定问题，具体而言即卖淫人员从嫖资总额中的获利分成是否应当计入被告人犯容留卖淫罪的非法获利数额。实践中对此争议较大，目前有三种意见：第一种意见认为，应参照组织卖淫罪的理解和实务操作，将从嫖娼人员处收取的全部嫖资总额认定为容留卖淫者的非法获利数额，卖淫人员的获利分成属于容留卖淫者的犯罪成本，从而在认定犯罪构成和判决追缴违法所得时均不扣除卖淫人员的获利分成。第二种意见认为，卖淫人员的获利分成不属于容留卖淫者的犯罪成本，故在认定行为人容留卖淫罪的犯罪构成和追缴违法所得时，均应当扣除卖淫人员的获利分成。第三种意见采取折衷的观点，认为在认定犯罪构成时，容留卖淫者的非法获利金额为收取的嫖娼总额；在追缴容留卖淫者个人违法所得时，应扣除卖淫人员的获利分成。笔者同意第二种意见，主要理由如下。

1. 容留卖淫者与卖淫人员是两个基本平等主体之间的相互利用的合作关系，不能简单参照组织卖淫罪的处理模式认定非法获利。第一，在容留卖淫犯罪中，容留者与卖淫人员自愿达成合意，即容留者提供场所，卖淫人员进行卖淫活动，双方按照一定比例获取各自的嫖资分成。双方是相互利用的平等合作关系，共同促成卖淫交易并从中获利。第二，容留卖淫者没有组织卖淫者对卖

淫人员的管理、控制特征。在组织卖淫案件中，组织者对卖淫人员有控制、管理关系，故将嫖客支付的全部嫖资认定为组织卖淫者的非法获利没有问题。一方面，组织者对卖淫人员从事卖淫活动的相关事项制定、确立管理规定，通过内部管理手段与卖淫人员之间形成管理和被管理的关系。另一方面，组织者建立卖淫组织对外提供服务，对于卖淫价格、嫖资分成比例等具有主导性的决定权。然而容留卖淫者通常是提供固定或者临时租借的场所以及流动场所的单一行为，而没有相应的管理、控制行为。容留卖淫案件中，卖淫人员对卖淫时间、对象、价格甚至分配嫖资的比例等事项具有一定的自主决定权，可以提出意见进而与容留卖淫者协商确定，两者的地位和人身依附性截然不同。

2. 容留卖淫罪的核心犯罪行为是容留，相应的非法获利也应当与该行为对等对价。容留卖淫活动由容留行为和卖淫行为两部分构成，其中卖淫行为被评价为违法行为，容留介绍行为达到一定程度被评价为犯罪行为。两者既非共同犯罪关系，也非由同一部法律进行规制，分属不同的部门法调整。容留卖淫罪惩治的是“容留”的犯罪行为，而并不包括“卖淫”的违法行为，后者由治安处罚法惩治，并非刑法调整的范畴；故容留卖淫罪犯罪构成中的“非法获利”对应的只能是“容留”的犯罪行为的非法获利，具体到案件而言，可以理解为卖淫人员向其缴纳的场所费用，而不能囊括“卖淫”的非法获利。后者属于治安处罚法规制的范畴，应由公安机关以治安处罚的方式处置。如果法院将包含卖淫人员获利分成的全部嫖资总额作为容留卖淫者的非法获利数额认定并判决追缴，则不仅会与公安机关查处卖淫人员时的追缴行为重复评价，而且有可能导致越权。

3. 从罪责刑相适应的原则出发，当以非法获利数额作为定罪量刑的主要依据时，非法获利数额的认定应当与行为的社会危害性大小相一致。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，容留、介绍他人卖淫非法获利1万元以上不满5万元的，构成容留、介绍卖淫罪，判处5年

以下有期徒刑、拘役或 者管制，并处罚金；非法获利5万元以上的，属于容留、介绍卖淫罪情节严重 的情形，应当判处5年以上有期徒刑，并处罚金。故，非法获利数额的认定，

直接关系到被告人是否属于容留卖淫“情节严重”的加重处罚情节而在5年以上还是以下幅度内量刑，与被告人的合法权益密切相关。如果将收取的嫖资总额认定为容留卖淫者的非法获利，则实践中容留卖淫者的非法获利数额很容易超过5万元，往往要被判处5年以上有期徒刑；而危害更大的组织卖淫罪，在非法获利100万元以下时，量刑幅度为5~10年有期徒刑。这就造成对容留卖淫者和组织卖淫者在非法获利5万~100万区间的对等、同等评价的后果，而客观上两者的社会危害性远不能相提并论，显然与罪责刑相适应原则不符。